

1500237-62.2022.8.26.0430

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUAN CASAGRANDE

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... acusados quanto ao crime de associação para o tráfico é medida que se impõe.

Nesse sentido, entende a jurisprudência: APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE

ENTORPECENTES. AUTORIA INCOMPROVADA. VIABILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO.

ABSOLVIÇÃO. Tráfico ilícito de entorpecentes. A negativa de autoria sustentada pela ré, que é primária, não resultou infirmada no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Vara Única

R. XV de Novembro, 809, Paulo de Faria - SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500237-62.2022.8.26.0430 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500237-62.2022.8.26.0430

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVES LUCAS FERNANDES e outro

Juiz de Direito: Dr.LUAN CASAGRANDE

Vistos.

Trata-se de ação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de IVES LUCAS FERNANDES, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 28, 33, "caput", e 35, todos da Lei 11.343/06, e contra ROBERTO SCHENTL, dando-o como incurso na prática do crime previsto no artigo 35 Lei 11.343/06.

Narra a denúncia: "Consta do presente auto de prisão em flagrante delito que, em data incerta, porém anterior ao dia 15 de maio de 2022, na cidade de Orindiúva, IVES LUCAS FERNANDES, qualificado e interrogado a fls. 8-9, associou-se com ROBERTO SCHENTL, qualificado e interrogado a fls. 12-13, para praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas. Consta ainda do presente auto de prisão em flagrante delito que, no dia 15 de maio de 2022, por volta das 19h59, na Vicinal Francisco Munhoz Porcel, na cidade de Orindiúva, comarca de Paulo de Faria, IVES LUCAS FERNANDES, qualificado e interrogado a fls. 8-9, trazia consigo e guardava, aproximadamente 1389,35g de cocaína, divididas em duas porções, que seria utilizada para a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 31-32, laudo pericial de fls. 35-39; 170-172; a quantia de R\$1.760,00; um celular Samsung Galaxy; um celular Motorola; uma balança de precisão. Consta ainda do presente auto de prisão

em flagrante delito que, no dia 15 de maio de 2022, por volta das 19h59, na Vicinal Francisco Munhoz Porcel, na cidade de Orindiúva, comarca de Paulo de Faria, IVES LUCAS FERNANDES, qualificado e interrogado a fls. 8-9, trazia consigo para consumo próprio 14,07g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 31-32, laudo pericial de fls. 35-39; 170-172. Consta também do presente auto de prisão em flagrante delito que, no dia 15 de maio de 2022, por volta das 23h00, na Avenida Alberto Andaló, 3282, apto 94, São José do Rio Preto (residência do denunciado Ives), IVES LUCAS FERNANDES, qualificado e interrogado a fls. 8-9, tinha em depósito e guardava, aproximadamente 784,84g de cocaína, divididas em 04 porções, e uma peneira, que seria utilizada para a mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo já requisitado pela autoridade policial). Conforme apurado, no dia 15 de maio de 2022, por volta das 19h59, na Vicinal Francisco Munhoz Porcel, na cidade de Orindiúva, os policiais militares avistam o denunciado Ives conduzindo o veículo VW/Fox 1.0, placa DTU5H73, São José do Rio Preto, Chassi 9BWKA05Z174139883, ano de fabricação 2007, ano do modelo 2007, cor preta, pela via pública, juntamente com o denunciado Roberto Schentl. Ao realizarem a abordagem, os policiais militares fizeram a busca pessoal no denunciado Ives e com ele foi encontrado 14,07g de maconha para consumo próprio e ainda R\$1.760,00. Com o denunciado Roberto, nada foi encontrado. Todavia, quando os policiais procederam a busca no veículo, foi localizada no porta-malas uma mochila de cor marrom, contendo em seu interior 1389,35g de cocaína, divididas em duas porções, bem como uma balança de precisão. O denunciado Ives informou que a maconha era para consumo próprio, enquanto que a cocaína seria para distribuição a pequenos traficantes nas cidades de Iturama e Fronteira, no estado de Minas Gerais. Ainda durante a abordagem, por volta das 23h00, Ives autorizou que os policiais militares realizassem diligência em sua residência, localizada na Avenida Alberto Andaló, 3282, apto 94, São José do Rio Preto, onde foram encontradas 784,84g de cocaína, divididas em 04 porções, e uma peneira. Assim, a quantidade de drogas, a forma de acondicionamento, além das circunstâncias da apreensão, demonstra que os entorpecentes se destinavam ao tráfico. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia IVES LUCAS FERNANDES como incurso nos artigos 28, 33, "caput", e 35, todos da Lei 11.343/06 e ROBERTO SCHENTL como incurso no artigo 35 Lei 11.343/06. Requer-se que os denunciados sejam notificados para apresentar resposta, prosseguindo-se nos demais atos do processo, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas, nos termos dos artigos 55 e seguintes da Lei 11.343/2006, até final condenação.

Os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 247-253 e 264-270).

Recebida a denúncia (fls. 282-285), foi designada audiência de instrução e julgamento, a qual foi realizada no dia 06 de setembro do corrente ano. Na oportunidade foram ouvidas duas testemunhas de acusação, Bruno Ribeiro de Castro Sampaio e Lucas Fernandes Costa, a testemunha Dilamar Cristina Silva, bem como, interrogado os acusados.

As partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a procedência dos pedidos, nos termos da denúncia.

A defesa do acusado Roberto Schntl postulou pela absolvição do acusado dada a inexistência de elementos de prova suficientes que comprovem seu envolvimento na prática do ilícito. Por sua vez, a defesa De Ives Lucas Fernandes, sustentou, de forma preliminar, a nulidade das provas obtidas, na medida em que foi realizada busca pessoal e veicular sem fundada suspeita que desse ensejo à mesma, e que os acusados foram ouvidos em sede inquisitorial sem que lhes fosse advertido do direito ao silêncio. No mérito, vindicou pela absolvição, e de forma subsidiária, postulou pelo reconhecimento da atenuante da confissão, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime mais benéfico de cumprimento de pena e a fixação de penas restritivas de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO NAS OITIVAS DOS ACUSADOS EM SEDE INQUISITORIAL.

A defesa do acusado Ives Lucas Fernandes aduziu que subsiste nulidade no presente feito, em razão da ausência de fundada suspeita que pudesse justificar a abordagem policial. O argumento não merece acolhimento. Ouvidos em sede de contraditório, ambos os policiais prestaram depoimentos firmes e harmônicos, onde aduziram que estavam realizando patrulhamento pela vicinal que dá acesso à cidade de Orindiúva, quando flagraram o veículo conduzido pelo acusado realizando manobra na rotatória, em alta velocidade, o que justificou a abordagem, porquanto suspeitaram que algo de ilícito pudesse haver. O próprio policial Lucas, ao ser ouvido em juízo afirmou " , e próximo ao trevo da rotatória, nos deparamos com o veículo Fox de cor preta, fazendo a rotatória em alta velocidade e adentrando no sentido à cidade de Orindiúva, e foi o que despertou a realização da abordagem". Vê-se, pois, que diferentemente do que narrado pela defesa, houve conduta prévia levada a efeito pelo motorista do veículo que chamou a atenção dos policiais que realizavam o patrulhamento, e diante disso, a abordagem foi levada a efeito, o que a entender deste juízo, é o bastante para que a busca seja levada a efeito. Nesse sentido: Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. PRELIMINAR DE NULIDADE da prisão em flagrante decorrente de ausência de "fundada suspeita" a justificar a abordagem do veículo. Inocorrência. Policiais militares teriam avistado o veículo em alta velocidade, passando por uma rotatória. Ausência de ilegalidade flagrante a justificar o trancamento pela sumária via do writ. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Considerável quantidade de entorpecente apreendido tanto no porta-malas do veículo como na residência do paciente. Periculum libertatis. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 21231813820228260000 SP 2123181-38.2022.8.26.0000, Relator: Amable Lopez Soto, Data de Julgamento: 04/10/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/10/2022). G.n.

Quanto à nulidade por ausência de advertência do direito ao silêncio, subsistem nos autos elementos que demonstram ter o acusado, de pronto, confessado ser usuário da substância entorpecente, tão logo a mesma foi encontrada em sua posse, tendo se seguido a revista veicular. Entendo, portanto, que inexistem nos autos elementos que demonstrem qualquer tipo de nulidade no proceder dos policiais, e mesmo que houvesse algum tipo de nulidade, esta teria ocorrido em sede inquisitorial, não tendo o condão de contaminar a ação penal, onde todos os direitos e garantias constitucionais de ambos os acusados foram devidamente observados. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ANTES DE QUE SEJA JUNTADA AOS AUTOS MÍDIA DO INTERROGATÓRIO DO RÉU CONDUZIDO EM SEDE INQUISITORIAL. NULIDADE INEXISTENTE. ILEGALIDADE EM FASE INQUISITORIAL QUE NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não configura nulidade a determinação, pelo juízo de 1º grau, de que as partes apresentem alegações finais antes de que seja juntada aos autos mídia do interrogatório do réu conduzido em sede inquisitorial, como solicitado pela defesa, pois, ainda que fosse demonstrado que o referido interrogatório não corresponde à real declaração do réu sobre os fatos, tal ilegalidade, por si só, não teria, necessariamente, o condão de determinar a absolvição do recorrente, sobretudo tendo em conta que, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial." (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018). Precedentes. 3. O reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. Precedentes desta Corte e do STF. Não se vislumbra prejuízo concreto decorrente da determinação de apresentação de alegações finais,

antes de ter sido juntada aos autos a mídia digital do interrogatório do réu conduzido na fase inquisitorial, se eventuais declarações inverídicas existentes no interrogatório efetuado em sede policial podem ser refutadas pelo recorrente quando ouvido em juízo. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 145950 SP 2021/0114151-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2021)g.n. Portanto, afasto as preliminares suscitadas e passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Os pedidos merecem acolhimento em parte.

A autoria e materialidade dos delitos de uso e tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01-02), Boletim de Ocorrência (fls. 24-28), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 31-32) e Laudos Periciais (fls. 35-39/170-172, e 496 e seguintes), que detectaram a presença da substância Cocaína e Tetrahydrocannabinol. Por sua vez, o contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório dá respaldo à acusação.

A testemunha Bruno Ribeiro de Castro Sampaio, policial militar, afirmou que estavam em patrulhamento pela vicinal Francisco Munhoz Porcel, vicinal que dá acesso ao município, quando visualizaram um veículo Fox preto, realizando o trevo de acesso a cidade em alta velocidade. Afirmou que acharam estranho e resolveram fazer a abordagem. Disse que o motorista obedeceu o sinal de parada e então realizaram a busca pessoal, momento em que foi localizado com o Ives a droga "Skank" e dinheiro. Afirmou que procedeu com a busca veicular, e localizou na porta malas uma mochila marrom com grande quantidade de pó branco, bem como uma balança de precisão. Afirmou que foi dada voz de prisão e conduzido até a central de flagrantes de Nova Granada. Questionado, aduziu que os acusados narraram que estavam em um prostíbulo na cidade de Fronteira e tiveram um desentendimento com outros clientes, quando então saíram e vieram até a pousada de Orindiuva e posteriormente iriam adentrar na cidade, onde foi realizada a abordagem. Questionado, confirmou que no momento da abordagem o Ives confessou que a droga "Skank" seria para o seu uso pessoal, e que a cocaína ele mesmo fabricava e distribuía em pequenas cidades da região, como Iturama, Fronteira e até mesmo em Rio Preto. Por sua vez, o Roberto, alegou que estava apenas de carona e não sabia da existência do entorpecente. Sobre a origem do dinheiro, o Ives disse que teria vendido algumas peças de computador. Questionado, aduziu que nenhum objeto inerente a computador ou mercancia lícita foi encontrada no veículo. Sobre a apreensão da droga "Skank", afirmou que faz seis anos que trabalha na região e que nunca havia apreendido essa droga antes. Da mesma forma, afirmou que nunca havia apreendido tamanha quantidade de cocaína.

Questionado pela defesa, disse que a via em que foi feita a abordagem é uma via estadual até a entrada da cidade, e que é comum realizar o patrulhamento e abordagem no local. Aduziu que foi a primeira vez que apreendeu drogas na vicinal. Questionado, disse que foi dada ordem de parada, foi pedido pra que descessem do veículo de mãos para cima, realizada a revista nos ocupantes inicialmente e posteriormente foi realizada a revista veicular. Afirmou que posteriormente foram encaminhados para a central e na delegacia foi realizada a identificação. Afirmou que o Ives não possuía documentos, e que foi tentado contato com algum familiar, mas não houve êxito. Afirmou que foram até a residência do Ives para tentar localizar algum documento e que nesse momento o Ives ficou na delegacia..

A testemunha Lucas Fernandes Costa, policial militar, informou que no dia dos fatos estava em patrulhamento pela vicinal Francisco Munhoz Porcel, e próximo ao trevo da rotatória, se depararam com o veículo Fox de cor preta, fazendo a rotatória em alta velocidade e adentrando no sentido à cidade de Orindiuva, e foi o que despertou a realização da abordagem. Disse que retornaram, pois estavam no contrafluxo, e fizeram a abordagem pela vicinal mesmo. Narrou que o acusado logo em seguida parou o veículo, quando então foi realizada a revista pessoal e foi localizado no bolso da blusa uma quantia em dinheiro em espécie, e uma porção da droga "Skank". Disse que indagou o Ives sobre a substância e o mesmo afirmou que a droga era para consumo próprio. Aduziu que em revista ao Roberto, nada de ilícito foi encontrado. Narrou que seu parceiro realizou a revista veicular, e localizou na porta malas, dentro de uma mochila, continha uma quantia de pó branco, e balança também.

Indagado o Ives sobre a substância, o mesmo aduziu que a droga era dele, que ele produzia e costumava entregar para pequenos traficantes da região. Questionado, o Ives disse que estava na cidade de Fronteira e se desentendeu com algumas pessoas e veio embora, e iria passar por dentro da cidade para ir embora para Rio Preto, mas o acusado disse que em Orindiuva não ia ficar a droga. Afirmou que Orindiuva não é necessariamente caminho para a cidade de Rio Preto. Afirmou que trabalha na cidade há sete anos, e nunca apreendeu essa quantidade de cocaína, e que nunca havia apreendido a droga "Skank" antes. Afirmou que o Roberto lhe disse que não tinha conhecimento da droga. Questionado pela defesa, afirmou que o Cabo Sampaio ficou na segurança e o depoente realizou a abordagem aos indivíduos, e que posteriormente o depoente ficou com os acusados e o seu colega realizou a revista do veículo. Questionado, aduziu que conversou com os acusados, e que estavam todos juntos. Questionado, respondeu que ao ser localizada a substância no bolso do acusado Ives, este de pronto confessou que a substância era destinada ao seu uso, e sobre a droga encontrada no veículo, depois o Ives relatou que ele mesmo produzia e comercializava para pequenos traficantes da região. Questionado, afirmou que Ives estava sem documento, e em conversa com o sargento, o Ives entregou a chave da sua residência, para que fosse até sua residência em São José do Rio Preto, a fim de que fosse feito o contato com a mãe para que fosse entregue um documento.

Questionado, disse que não sabe se o Ives morava ou não com a mãe e que o Ives estava com a chave da residência.

A informante Dilamar Cristina Silva, genitora do acusado, aduziu que era depois das 23 horas de noite, o telefone tocou, atendeu e se identificaram como policiais, perguntando se era a residência do Ives. Disse que não, as mas se identificou como sua genitora. Disse então que pediram para que fosse até o portão, quando lhe narraram que o Ives havia sido preso e necessitava de um documento. Disse que respondeu inexistir qualquer documento em sua residência mas que iria procurar. Disse ter respondido que não encontrou nada e que iria entrar, quando então o policial pediu se poderia entrar com a depoente. Disse que autorizou que um dos policiais entrassem e foi até o quarto onde o Ives costumava ficar quando lhe visitava. Disse que quando saiu do quarto, constatou outros policiais no interior da sua residência. Disse que não havia dado autorização para outras pessoas adentrarem na sua residência. Aduziu que um dos policiais aduziu que alguém deveria ir até a delegacia. Disse que não poderia ir, mas que ligaria para o irmão que residia em Araçatuba. Questionada, aduziu ter descoberto que o acusado Ives estava usando substância entorpecente, que era usuário de cocaína, pois notou ter o mesmo ficado mais violento e respondia grosseiramente aos questionamentos.

Interrogado, o acusado Roberto Schentil exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Interrogado, o acusado Ives Lucas Fernandes, aduziu que encontrou com o Roberto próximo a um bar e foram sair para ir até um rancho. Narrou que o Roberto nada tem a ver com a situação. Disse que era usuário e estava usando muita droga. Disse que a droga era sua e iria dividir entre seus amigos, por isso que estava no carro. Narrou estar arrependido e que ao sair da prisão mudará de vida.

Antes de adentrar em cada crime, cabe ressaltar que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais são coerentes e harmônicos entre si e com aqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Não há qualquer motivo para levar a crer que os policiais teriam algo contra os réus para que os incriminassem falsamente. Logo, seus depoimentos merecem crédito. Saliente-se que o simples fato de as testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova colhida, mormente quando os depoimentos vêm amparados em outros elementos de convicção, como no caso. A esse respeito a jurisprudência é remansosa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA POLICIAL. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, bem assim a apreensão de faca, balança de precisão, sacos plásticos para embalar a droga (cocaína), comprovando com a necessária certeza a prática do crime de tráfico. 2. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para a respaldar

o decreto condenatório, especialmente quando não se apresenta qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20180110124917 DF 0002669-27.2018.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 05/09/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/09/2019 . Pág.: 127/135); TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÃO. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL E TESTEMUNHAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. Destaca-se que os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Aqui, em prova convincente, os policiais informaram que, depois de investigações e munidos de mandado de busca e apreensão, constataram que os apelantes tinham em depósito, para tráfico, grande quantidade de entorpecente e munição. Seus depoimentos foram confirmados por testemunhas ligadas aos dois recorrentes. Além disso, ficou constado que eles estavam associados para o cometimento dos delitos. DECISÃO: Apelos defensivos parcialmente providos. Unânime. (Apelação Crime Nº 70056731045, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 21/03/2018). (TJ-RS - ACR: 70056731045 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 21/03/2018, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018);

DO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006

Os policiais militares, ouvidos juízo, afirmaram de forma uníssona que ao revistarem o acusado Ives, encontraram com o mesmo uma pequena porção de maconha. Em seu interrogatório, o acusado Ives confessou que na época em que foi preso estava fazendo muito uso de substâncias entorpecentes, circunstância esta que vem corroborada pelas informações trazidas aos autos por sua genitora, que confirmou ter descoberto que seu filho fazia uso de substâncias entorpecentes. Entendo, portanto, que existem nos autos elementos suficientes que demonstram a prática do ilícito pelo acusado, que com sua conduta incorreu na prática do delito previsto no art. 28, da lei 11.343/06, in verbis:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - Advertência sobre os efeitos das drogas;

II - Prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Nesse sentido, entende a jurisprudência: POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. Pedido de absolvição por atipicidade. Prova da materialidade demonstrada por laudo pericial e autoria por depoimentos de testemunhas e a confissão judicial. Policiais e demais agentes públicos não são impedidos de depor e eventual interesse na causa ou malícia devem ser demonstrados. Conduta que se encontra tipificada em lei e que atende aos princípios constitucionais e não pode ser tida como insignificante. Conjunto probatório coerente que autoriza a condenação pela prática do crime do art. 28 da Lei 11.343/06. (TJ-SP - APR: 00246337620168260564 SP 0024633-76.2016.8.26.0564, Relator: Fernando Martinho de Barros Penteado, Data de Julgamento: 07/02/2020, Turma Criminal, Data de Publicação: 12/02/2020).

DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006

Conforme exposto pelos policiais militares ouvidos em juízo, foi realizada a abordagem do veículo conduzido pelo acusado Ives quando trafegava pela vicinal que dá acesso à cidade de Orindiuva, quando foi realizada a abordagem. Após realizada busca pessoal ao acusado Ives, onde parte da substância entorpecente foi encontrada em sua vestimenta, foi realizada inspeção veicular onde foi encontrado no porta-malas do veículo elevada quantidade de substância entorpecente, cuja massa bruta é de 1389,35 gramas. O Laudo Pericial de fls. 35-39 demonstra:

Além da substância entorpecente encontrada no veículo conduzido pelo réu, onde foi ainda encontrada uma balança de precisão, a denotar seu envolvimento habitual e sua dedicação na prática do delito de tráfico de drogas. No ponto, ao ser interrogado, o próprio acusado admitiu que a substância entorpecente lhe pertencia, que o corréu Roberto nada sabia acerca do entorpecente, e que pretendia dividir as drogas com outros usuários. Posto isto, considerando a elevada quantidade da substância

entorpecente apreendida na posse do réu Ives, entendo que com sua conduta incorreu na prática do crime de tráfico previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, in verbis: Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse sentido, entende a jurisprudência: Apelação - Tráfico - Conduta de trazer consigo, para o tráfico, 18 pedras de crack (peso líquido de 5,20 gramas), 26 pinos de cocaína (peso líquido total de 5,75 gramas), e outros 78 pinos também de cocaína (peso líquido total de 18,32 gramas) - Recursos defensivos que buscam a absolvição por alegada fragilidade probatória ou desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Negativa dos réus desmentidas pelos depoimentos dos policiais, os quais se mostraram firmes e coerentes - Validade para embasar decreto condenatório - Circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecentes a demonstrar a destinação da droga à venda - Penas impostas ao corréu CARLOS, todavia, que comportam alteração - Quantidade não expressiva - Anterior condenação do corréu CARLOS pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas sem trânsito em julgado - Réu primário, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas - Fixação da pena-base no mínimo legal - Possibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4º em seu patamar máximo - Abrandamento do regime prisional para o aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos - Possibilidade - Recurso do Ministério Público (que buscava o afastamento do redutor em relação ao corréu LUCAS e fixação de regime fechado para ambos os réus) e do corréu LUCAS desprovidos, provido, em parte, o de CARLOS. (TJ-SP - APR: 00010841020178260594 SP 0001084-10.2017.8.26.0594, Relator: Osni Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2019, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/04/2019).

No que diz respeito às substâncias localizadas na residência do acusado Ives, consoante laudo pericial encartado aos autos, as mesmas não são substâncias entorpecentes, de modo que, no ponto, não há que se falar na prática do delito de tráfico de drogas.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006

No que tange ao crime de associação para fins de tráfico, inexistem elementos suficientes para autorizar a prolação de um édito condenatório. Os policiais militares informaram terem encontrado uma pequena porção de entorpecente que estava na posse do acusado Ives e que a cocaína estava no porta-malas do veículo. Inexistem nos autos elementos de prova indicativos de que Ives e Roberto, com ajuste prévio e estabilidade de propósito tenham se associado para atividade de tráfico, crime este que se encontra previsto no art. 35 da Lei 11;343/06, in verbis:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Dessa forma, por não haver provas suficientes, a absolvição dos acusados quanto ao crime de associação para o tráfico é medida que se impõe. Nesse sentido, entende a jurisprudência: APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA INCOMPROVADA. VIABILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. Tráfico ilícito de entorpecentes. A negativa de autoria sustentada pela ré, que é primária, não resultou infirmada no confronto com os demais subsídios de prova carreados aos autos. Impositiva a reversão do juízo condenatório. A prisão do seu companheiro, ocorrida no dia anterior, impõe dúvidas sobre o eventual possuidor da substância, encontrada enterrada no jardim, pois a ré negou inclusive ser usuária. Associação para o tráfico. Não restou demonstrada a efetiva participação da acusada na prática

do tráfico ilícito de entorpecentes. Ausentes provas de que a apelante se encontrava em permanente intenção associativa para atuar em conjunto na comercialização de substâncias entorpecentes, impositiva a absolvição. APELAÇÃO PROVIDA. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. (Apelação Crime Nº 70052574704, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 28/02/2013) (TJ-RS - ACR: 70052574704 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 28/02/2013, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/03/2013).

Diante do exposto, a pretensão punitiva procede parcialmente.

Passo à dosimetria.

Nessa tarefa, cabe observar o critério trifásico (art. 68 do CP) e os princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

Nesse sentido, o Código Penal prevê que o patamar da pena deve ser “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 59, caput).

Ademais, no tocante especificamente aos crimes previstos na Lei 11.343/06, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (art. 42).

DOSIMETRIA

DO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006

No presente caso, tendo em vista a quantidade e diversidade da substância entorpecente apreendida, entendo que a simples advertência por si só é insuficiente para a reprovação de sua conduta. Por essa razão, entendo que deve ser cominada a pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de cinco meses nos termos do art. 28, II, 3 §3º, da Lei nº 11.343/2006.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006

1ª FASE. PENA BASE

Com relação à culpabilidade, normal em crimes dessa natureza. O réu não possui antecedentes criminais, inexistindo nos autos elementos de prova desfavoráveis sobre sua conduta e personalidade. Os motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do delito são negativas, pois valeu-se de veículo automotor para praticar o transporte do entorpecente, a fim de que o comércio e distribuição do entorpecente fosse facilitado, bem como, estava circulando em alta velocidade pela rodovia, consoante pacífico depoimento prestado pelos policiais que realizaram a abordagem, a denotar maior gravidade do caso objeto de análise. Por fim, as consequências do crime mostram-se normais ao tipo.

Diante do exposto, considerando a existência de uma circunstância negativa, entendo que a pena-base deve se afastar do mínimo legal. Assim, exaspero a pena em 1/6, passando a dosá-la em 05 anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como, ao pagamento de pagamento de 583 dias-multa.

2ª FASE. PENA INTERMEDIÁRIA

Inexistem circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante da confissão, na medida em que o acusado confessou a prática do ilícito, e o faço com fundamento no art. 65, III, “d”, do CP. Diante disso, atenuo a pena, conduzindo-a novamente ao mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

3ª FASE. PENA DEFINITIVA

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena passíveis de valoração. Anoto que, nos termos em que já exposto em fundamentação, o acusado não faz jus à minorante do art. 33, §4º, posto que existem nos autos elementos suficientes que indicam sua dedicação na prática habitual de atividades criminosas, como quantidade elevada do entorpecente encontrado em sua posse, suficiente para atingir mais de mil usuários, a diversidade da substância apreendida, e a presença de um balança de precisão, utilizada costumeiramente para o fracionamento e pesagem dos entorpecentes, o que indicam a mercancia do produto. Tais circunstâncias, aliadas à utilização de veículo automotor para distribuição do entorpecente, a toda evidência, confirmam seu envolvimento e dedicação do acusado na prática do ilícito, a indicar que não se trata de pequeno traficante de drogas, mas sim, de pessoa que exerce função importante na atividade delituosa, disseminando o comércio de

substâncias altamente nocivas no meio social. Por tais razões, entendo que o afastamento do privilégio é medida de rigor. Nesse sentido: AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS A EVIDENCIAR A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. II - No presente caso, não se considerou o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza, diversidade e quantidade de droga apreendida, qual seja "63 gramas de crack, 193 gramas de cocaína e 1,45 gramas de maconha - fls. 71/72)". Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado. Precedentes. III - Quanto ao estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena, a quantidade e a natureza da droga foram utilizadas, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastar a incidência da redutora do tráfico privilegiado, sendo, portanto, consideradas como circunstâncias desfavoráveis, a ensejar a aplicação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. Agrado regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1472514 MG 2019/0089940-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 30/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019); PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. A diversidade e a quantidade de droga justificam a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 199227 SP 2011/0046931-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015).

Diante disso, torno a pena definitiva em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa..

VALOR DO DIA MULTA

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Cabe reconhecer que o delito cometido é equiparado a hediondo (art. 2º da Lei 8.072/90 e Súmula 510 do STJ), mas a hediondez por si só não justifica a imposição de regime fechado (Tema 972 da repercussão geral do STF), surtindo efeitos apenas na esfera de execução da pena. Pelo montante da pena, bem como, pela diversidade do entorpecente e quantidade expressiva encontrada, bem como, pelo modus operandi, entendo que a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO (art. 33, §§2º e 3º, e art. 42 da Lei nº 11.343/2006 do Código Penal). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA Pelo montante da pena (maior que 4 anos), incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77 do CP).

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DETRAÇÃO (art. 387, §§ 1º e 2º do CPP)

O acusado responde ao processo recluso, e no presente caso, inexistem motivos para sua colocação em liberdade. Consoante se verifica dos argumentos acima expendidos, a conduta ilícita do réu quanto ao crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada. Ademais, não se trata de um delito de tráfico qualquer, com baixo potencial lesivo, mas sim, de uma apreensão de elevada quantidade do entorpecente,

capaz de atingir mais de mil usuários da substância. Jamais foi realizada tamanha apreensão na localidade, tendo os próprios policiais aduzido, em juízo, que em todo o período em que são policiais, jamais apreenderam tamanha quantidade do entorpecente. A quantidade da droga, aliado à diversidade do entorpecente apreendido, à existência de balança de precisão, denotam, evidentemente o comércio dos entorpecentes e indicam a gravidade em concreto do ilícito. Por conseguinte, além disso, o acusado valia-se de veículo automotor para disseminar a prática do comércio mortal pela região. Não se trata, portanto, da prática de um delito de gravidade em abstrato, apenas, mas da presença da gravidade em concreto da conduta levada a efeito pelo acusado. A circunstância de ser primário até então, não afasta ou diminui a ilicitude de seu comportamento, pois se assim fosse, nenhum acusado com a condição de primário teria sua prisão preventiva decretada. Diante dos elementos expostos acima, e na fundamentação da presente sentença, entendo que a prisão preventiva permanece necessária, não apenas para garantir a ordem pública, inibindo a prática de crimes dessa natureza, de elevada gravidade, mas para assegurar a aplicação da lei penal, evitando que o acusado fuja das consequências do ilícito praticado e pelo qual restou condenado.

VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO

Deixo, ademais, de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não haver instrução e pedido a respeito de eventuais danos sofridos. A esse respeito, cito a lição de Guilherme de Souza Nucci: "Admitindo-se que o Magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los" (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., 2008, p. 691).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para: CONDENAR IVES LUCAS FERNANDES à pena de prestação de serviço à comunidade pelo período de 05 (cinco) meses, em razão da prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06;

CONDENAR IVES LUCAS FERNANDES à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06;

ABSOLVER IVES LUCAS FERNANDES e ROBERTO SCHENTL, da imputação pela prática do delito previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Mantida a prisão preventiva, recomende-se a prisão do acusado Ives no estabelecimento prisional em que se encontra. Renove-se a contagem dos 90 dias. Por consequência da condenação, DECRETO O PERDIMENTO do veículo Fox - placa DTU5H73, em razão de sua evidente utilização na prática do ilícito, da quantia de R\$1.760,00 e do celular de Samsung Galaxy, em favor da União, o que faço com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 63 da Lei nº 11.343/2006.

Proceda-se com a destruição das substâncias entorpecentes e amostras, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/2006.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 398 das NSCGJ), o mandado de prisão e, após, seu cumprimento, a guia de recolhimento definitiva (art. 467 a 474 das NSCGJ; bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

P.I.C.

Paulo de Faria, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA